

<제3편 제1심의 소송절차.제05장 소송 개시와 심리 대상.제06절 재판장의 소장심사와 그 후의 조치>
[예상][5.06-1]보정기한 도과 후 각하명령 송달 전 흠결 보정 시 소장각하명령의 효력

《【문제5.6】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금 반환을 구하는 소를 제기하고자 서울중앙지방법원에 소장을 제출하였다. 그런데 甲은 소장에 乙의 주소를 기재하면서 서울 강남구 이하 불상이라고만 기재하였고, 청구원인에는 乙이 돈을 빌려가서 안 갚음이라고만 간략히 적어 제출하였다. 담당 재판장 A는 소장을 심사한 후 甲에게 7일 이내에 피고의 구체적인 주소를 보정하고 청구원인을 구체적으로 특정할 것을 명하는 보정명령을 내렸다.

위 보정명령은 2023. 10. 1. 甲에게 적법하게 송달되었으나, 甲은 2023. 10. 15.이 되어서야 보정서를 제출하였다. 한편, 재판장 A는 甲이 기한 내에 보정하지 않자 2023. 10. 10. 소장각하명령을 작성하였으나, 이 명령이 甲에게 송달되기 전인 10. 15.에 甲의 보정서가 법원에 도착하였다.

또 다른 사례로, 丙은 丁을 상대로 소를 제기하여 소장 부분이 丁에게 송달되었다. 그러나 丁은 주소지에 거주하지 않아 송달불능이 되었고, 재판장은 丙에게 주소보정을 명하였다. 丙은 丁의 소재를 알 수 없어 공시송달을 신청하였으나, 재판장은 요건 미비를 이유로 이를 받아들이지 않고 다시 주소보정을 명하며 이를 이행하지 않을 경우 소장을 각하하겠다고 통지하였다.

(물음1) 재판장 A가 내린 소장각하명령의 성질과 관련하여, 甲이 보정기한을 도과하였으나 각하명령이 송달되기 전에 흠결을 보정하였다면 재판장이 이미 작성한 소장각하명령을 그대로 집행할 수 있는지 여부를 판례의 태도에 근거하여 논하시오.》

<문제5.6의 물음1> 보정기한 도과 후 각하명령 송달 전 흠결 보정 시 소장각하명령의 효력

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 보정명령에서 정한 기간을 경과하여 소장의 흠결을 보정하였으나, 그 보정서가 재판장이 작성한 소장각하명령이 송달되기 전에 법원에 제출된 상황이다. 쟁점으로 <소장각하명령의 법적 성질과 보정기간을 도과한 흠결보정이 각하명령 송달 전에 이루어진 경우 재판장이 이미 작성한 소장각하명령을 그대로 송달·집행할 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 소장각하명령의 성질과 각하명령 송달 전 흠결보정이 이루어진 경우 소장각하명령의 효력을 논한다.

II. 재판장의 소장심사권과 보정명령

1. 소장심사권의 의의

- 재판장은 소장이 제출되면 소장의 방식 적합 여부를 심사한다. 이는 소송절차의 경제와 피고의 부당한 응소 부담을 방지하기 위한 제도다.

2. 보정명령 및 소장각하명령

(1) 보정명령

- 소장에 필요적 기재사항(당사자, 법정대리인, 청구취지, 청구원인)이 누락되었거나 규정에 따른 인지를 붙이지 않은 경우, 재판장은 상당한 기간을 정하여 보정을 명한다.

(2) 소장각하명령

- 원고가 보정기한 내에 흠결을 보정하지 아니한 때에는 재판장은 명령으로 소장을 각하하여야 한다. 이는 판결이 아닌 명령의 형식으로 이루어지는 재판이다.

III. 소장각하명령의 성질 및 효력 발생 시기

1. 명령의 성질

- 소장각하명령은 재판장이 소송지휘권의 일환으로 행하는 재판이다. 이는 법원의 판단이 대외적으로 표시됨으로써 효력을 발생하게 된다.

2. 효력 발생 시기(송달 시)

- 판결이 선고에 의해 효력이 발생하는 것과 달리, 결정이나 명령은 당사자에게 송달됨으로써 그 효력이 발생한다. 따라서 소장각하명령이 작성되었다 하더라도 원고에게 송달되기 전까지는 대외적으로 완전한 효력을 가졌다고 보기 어렵다.

IV. 보정기한 도과 후 송달 전 보정의 효력

1. 학설의 태도

(1) 긍정설

- 보정기한은 불변기간이 아니므로, 각하명령이 송달되어 효력이 발생하기 전까지 보정이 이루어졌다면 소 제기는 적법해진다는 견해다.

(2) 부정설

- 일단 보정기한이 도과하면 재판장의 각하 의무가 발생하므로, 사후적인 보정으로 이미 발생한 각하 사유를 치유할 수 없다는 견해다.

2. 판례의 태도

- 판례는 소장각하명령이 내린 경우라도 그 명령이 원고에게 송달되기 전에 원고가 재판장의 보정명령 취지에 따라 흠결을 보정하였다면, 재판장은 그 소장각하명령을 송달할 수 없고 소송절차를 진행하여야 한다는 입장이다. 즉, 보정기한을 도과했더라도 각하명령의 효력 발생 전에 보정이 이루어지면 흠결은 치유된 것으로 본다.

V. 사안의 적용

1. 보정의 유효성 판단

- 사안에서 甲은 보정기한인 2023. 10. 8.을 도과하여 10. 15.에 보정서를 제출하였다. 그러나 재판장 A가 작성한 소장각하명령은 아직 甲에게 송달되지 않은 상태였다. 판례의 취지에 따르면 소장각하명령의 효력이 발생하기 전에 흠결이 실질적으로 보정되었으므로, 재판장은 이미 작성된 각하명령을 집행(송달)할 수 없다.

2. 재판장이 취해야 할 조치

- 재판장 A는 甲의 보정서가 제출된 이상, 기존에 작성했던 소장각하명령을 파기하거나 집행하지 않아야 한다. 소장의 흠결이 보정된 것으로 간주하여 소장 부분을 피고 乙에게 송달하고 변론기일을 지정하는 등 정상적인 소송절차를 개시하여야 한다.

VI. 결론

- 재판장의 소장각하명령은 원고에게 송달됨으로써 효력이 발생한다. 따라서 보정기한이 지났더라도 각하명령이 송달되기 전에 원고가 흠결을 보정하였다면 소장의 적법성은 회복된다. 사안의 甲은 비록 기한은 어겼으나 명령 송달 전 보정을 완료하였으므로 재판장은 소장각하명령을 그대로 집행할 수 없으며, 소송을 계속 진행하여야 한다. 이는 원고의 재판청구권을 과도하게 제약하지 않으면서도 실질적인 보정을 유도하고자 하는 판례의 타당한 해석이다.